

1500888-93.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CESAR TAYAN BORGES GARCIA

Data da Audiência:

31/03/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500888-93.2021.8.26.0571 - Controle 2021/000918

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CESAR TAYAN BORGES GARCIA

Data da Audiência:

31/03/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, do representante do Ministério Público, do Defensor, o advogado Gustavo Gurgel, OAB 314619, e do Acusado César Tayan Borges Garcia. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas as testemunhas Alessandro Paques Rios e Paulo César Cassamassimo de Oliveira arroladas pelas partes. Em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, acha-se processada a acusada como incurso no artigo 33 da Lei de Tóxicos, em face dos fatos detalhadamente narrados na denúncia. Concluída a instrução, a ação penal merece proceder. A materialidade delitiva encontra respaldo no laudo de exame químico-toxicológico acostado aos autos. Autoria e existência delitiva, ao seu turno, vêm comprovadas nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Ouvidos em juízo e em solo policial, os guardas civis

responsáveis pela prisão do acusado narraram de forma segura e harmoniosa a dinâmica dos fatos. Afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram o acusado mantendo contato com outra pessoa em uma moto, pondo-se a correr em fuga com a aproximação da viatura. Diante disso realizaram a perseguição e o abordaram, sendo que puderam observar quando ele dispensou uma pochete, na qual continha dinheiro e 44 pinos de cocaína. Indagado, admitiu a posse da droga, sendo que num ponto próximo em um terreno baldio, com apoio do cão farejador, localizaram e apreenderam outras quatro grandes porções de maconha, drogas que se destinavam ao tráfico, pelo que o detiveram em estado flagrancial. As palavras dos guardas civis revestem-se de imensurável valor probatório, uma vez que isentas e desprovidas de qualquer intenção de prejudicar o agente. Demais disso, não há nenhum elemento capaz de indicar uma suposta suspeição dos servidores; ao contrário, revela de forma absolutamente convincente toda dinâmica da diligência que resultou na prisão em flagrante. Por outro lado, deita por terra a versão do acusado, a qual se mostra isolada no cenário dos autos, além do que imensamente fantasiosa, na medida em que tentou imputar o flagrante como uma farsa dos guardas civis, o que não está a merecer credibilidade. Portanto, demonstradas autoria e materialidade, pugna a Justiça Pública pela procedência da ação penal, condenando-se a acusada nos termos da denúncia, fixando-se regime inicial fechado para cumprimento da sanção carcerária. Além disso, cabe ressaltar a impossibilidade jurídica da aplicação do redutor, haja vista a elevada potencialidade lesiva da conduta, pois o acusado possuía elevada quantidade de entorpecentes, evidenciando forte abrangência da comercialização espúria a que se dedicava, tanto que atualmente encontra-se preso pela prática de tráfico e associação cometidos posteriormente aos fatos versados nestes autos. Dada a palavra ao Dr. Defensor, este se manifestou através do sistema audiovisual. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença:

Vistos. CESAR TAYAN BORGES GARCIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 29 de junho de 2021, por volta das 17 h, na Rua Silas Cardoso, n. 06, Bairro São Camilo, nesta Cidade e Comarca, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, quarenta e quatro pinos de "cocaína", com peso de 7,30 gramas; quatro porções de "maconha", com peso de 78,78 gramas; e quatorze tijolos de "maconha", com peso de 9,475 quilogramas. Notificado, fls. 136, o Réu apresentou defesa preliminar, fls. 146/147. A denúncia foi recebida, fls. 148/149 e o Réu, citado, fls. 168. Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas presentes e realizou-se o interrogatório (gravação por videoconferência). Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a condenação e a Defesa, a absolvição. É o relatório. DECIDO. Afasto a preliminar de nulidade decorrente de prisão em flagrante executada por guardas municipais, pois não se vislumbra qualquer ilegalidade nesse particular. Não se desconhece as limitações constitucionais da atividade funcional dos guardas municipais (art. 144, § 8º), porém é certo que a Carta Magna não retira dos membros da GCM a condição de agentes de autoridade, legitimados a praticar atos de defesa à sociedade, sobretudo em situação de flagrância. Neste ponto registro que o artigo 301 do Código de Processo Penal é claro ao prever que qualquer do povo, as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. O contato mantido com o motociclista, a fuga do Réu e a dispensa da pochete contendo drogas demonstrou a necessidade de ação da Guarda Municipal e, de fato, o Réu trazia consigo entorpecentes em situação de flagrante delito, uma vez que se trata de crime permanente. A ação é procedente. A materialidade do delito de tráfico acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 12/14, no Auto de Exibição e Apreensão, fls. 15/16, no Laudo de Constatação, fls. 21/22, no relatório de investigação, fls. 95/117, bem como no Exame químico-toxicológico n. 212.743/2021, fls. 176/179, constatando-se a presença dos princípios ativos Tetrahydrocannabinol (THC) e Cocaína. Alessandro Paques Rios e Paulo César Cassamassimo de Oliveira, guardas municipais, testemunhas, disseram que estavam em patrulhamento quando se depararam com o Réu, que fazia contato com um piloto de motocicleta, o qual empreendeu fuga ao ver os policiais; o Acusado também fugiu e os guardas o

acompanharam, tendo visto o momento em que o Réu dispensou, em um terreno, uma pochete. Feita a abordagem, com o Acusado houve localização de um celular e de dinheiro, e, dentro da pochete, porções de entorpecentes. O Réu admitiu a propriedade e a venda de drogas. Com o auxílio de uma cadela farejadora houve localização de cinco tijolos de "maconha" e de uma balança de precisão, mas o Réu não admitiu a propriedade dessa droga. César Tayan Borges Garcia, Réu, ao ser interrogado, disse que tinha chegado do trabalho, pegou a moto e foi ao mercado, parou, desceu e, ao entrar no estabelecimento, foi abordado e conduzido à Delegacia de Polícia, onde soube que tinham "colocado" drogas. Viu algumas pessoas correndo, mas não entendeu o que ocorria. Confrontando-se a prova coligida, verifica-se que a condenação é medida que se impõe. Com efeito, os guardas municipais estavam em patrulhamento quando se depararam com o Réu, o qual fazia contato com um motociclista, que, ao ver a viatura, empreendeu fuga, mesmo comportamento adotado pelo Réu, o qual foi perseguido e, no caminho, dispensou uma pochete; ao ser abordado, com ele os guardas localizaram um celular e dinheiro, e, ao examinarem a pochete dispensada durante a fuga, os guardas encontraram quarenta e quatro pinos de "cocaína", com peso de 7,30 gramas; quatro porções de "maconha", com peso de 78,78 gramas. A diversidade, a quantidade, a forma de separação e a quantidade de porções demonstram claramente a finalidade mercantil. Ademais, havia dinheiro, fruto de vendas pretéritas, o que se infere das circunstâncias e da ausência de demonstração de ocupação lícita. O relatório de fls. 95/117, referente às conversas extraídas do whatsapp, demonstra a dedicação do Réu ao tráfico de entorpecentes e a utilização do aparelho como ferramenta para a venda de drogas. Por outro lado, os tijolos de "maconha" encontrados enterrados no terreno, o que decorreu do emprego de uma cadela farejadora, não podem ser imputados ao Réu porque não há demonstração de tal circunstância. Não houve campanhas para ver se ele se deslocava até esse local e também não foi visto em algum momento lá. Os guardas deram testemunhos firmes, coerentes, e descreveram de forma isenta os fatos como ocorreram. No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais e agentes da lei, há que se considerar que, por se tratarem de agentes públicos, gozam da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos. Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito: "É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). Portanto, de acordo com o examinado, está comprovado que o Réu trazia consigo substâncias entorpecentes, conduta esta que configura a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, "in casu", foi a de trazer consigo, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Evidente o dolo direto do agente, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Destarte, a pretensão procede integralmente. II - DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. - Art. 59, "caput", do Código Penal: Considero boas as circunstâncias judiciais, razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso. Art. 61 e art. 65, do CP: O Réu é menor de 21 anos, logo faz jus à atenuante. Todavia, na segunda etapa, as atenuantes não tem o condão de minorar a reprimenda aquém do piso legal. Esse é o entendimento consubstanciado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". - Art. 68, do CP: Considerando-se a quantidade de entorpecentes, aplico a causa de diminuição de pena e a reduzo em 2/3. Fixo-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e de 166 (cento e

sessenta e seis) dias - multa, no piso, que torno definitiva. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa "empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo", pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da Resolução n.º 5/12, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no último dispositivo legal acima mencionado. Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli). O Superior Tribunal de Justiça já vem se alinhando àqueles entendimentos, conforme se viu no julgamento do Habeas Corpus 176.919/DF, onde foi concedida a ordem para estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e para substituir esta por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2010, Dje 13/12/2010). Na hipótese, o réu havia sido condenado por tráfico de drogas, lhe sendo imposta uma sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, tendo sido reconhecida a sua primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, em razão da pena aplicada e das circunstâncias judiciais, o Réu poderá cumprir a pena no regime aberto, já considerada a detração. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Preenchidos os requisitos previstos nos incs. I, II e III, do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, e limitação de fim de semana. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar CESAR TAYAN BORGES GARCIA, qualificado nos autos, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário - mínimo vigente ao tempo da conduta, por incidir no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006. Substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena privativa de liberdade, e limitação de fim de semana. Decreto a perda dos bens e dos valores apreendidos. Deixo de condenar o Réu nas custas, ante a pobreza presumida. O Réu respondeu em liberdade ao processo, e, neste momento, ausentes as razões da custódia cautelar, poderá interpor eventual recurso nessa condição. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 31 de março de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA